N° 400807
Société Trane

4ème et 1ère chambres réunies
Séance du 24 septembre 2018
Lecture du 10 octobre 2018

CONCLUSIONS

Mme Sophie-Justine Lieber, Rapporteur public

L'absence de communication d'un mémoire de reprise d'instance, après le décès de l'une des parties, entache-elle d'irrégularité le jugement d'un TA ? C'est la question de procédure que pose ce contentieux du licenciement d'un salarié protégé.

En novembre 2011, la société Trane, filiale du groupe Ingersoll Rand, spécialisée dans les systèmes de traitement d'air (chauffage, ventilation, climatisation), avait mis à pied à titre conservatoire l'un de ses salariés, M. D...A..., technicien informatique : elle avait découvert, grâce à une alerte de sa société mère, que celui-ci copiait sur des ordinateurs personnels des données de la direction des ressources humaines et de la direction générale, confidentielles et stratégiques, auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès. L'employeur de M. A... a alors procédé à plusieurs sessions d'ouverture des ordinateurs de l'intéressé, auxquelles ce dernier n'a pas souhaité assister – sessions qui ont confirmé ces transferts de données. L'intéressé étant un salarié protégé en raison de sa candidature à l'élection des délégués au CHSCT, la société Trane a demandé et obtenu de l'inspectrice du travail, le 30 avril 2012, l'autorisation de le licencier. Mais sur saisine de l'intéressé, puis reprise de l'instance par son épouse et son fils après son décès, cette décision a été annulée par le TA de Nancy, qui a estimé que le caractère contradictoire de la procédure de licenciement n'avait pas été respecté. La société Trane a fait appel de ce jugement mais n'a pas obtenu gain de cause devant la CAA de Nancy ; elle se pourvoit donc en cassation contre son arrêt du 19 avril 2016.

1. Ce dossier a été admis en cassation sur le premier moyen soulevé par la société employeuse, tiré de l'erreur de droit de la CAA à avoir jugé que la procédure devant le TA avait été régulière, alors même que le mémoire signalant la reprise de l'instance par Mme F... A...et M. C...A...ne lui avait pas été communiqué. La société fait en effet valoir qu'elle n'a eu connaissance de cette reprise d'instance que via l'application Sagace, indiquant l'enregistrement d'un nouveau mémoire le 19 novembre 2014 – alors que le requérant était décédé dix jours auparavant. Elle a alors, explique-t-elle, contesté « *à l'aveugle* » la reprise d'instance, par un mémoire du 20 novembre 2014 (produit, donc, dès le lendemain), en demandant la production d'un certificat de décès et l'identité précise des repreneurs d'instance, afin de s'assurer qu'ils étaient bien ayants droits de M.A....

Pour rejeter le moyen d'irrégularité de la procédure, la cour a relevé tout d'abord que les parties avaient d'ores et déjà produit des écritures avant le décès de M.A..., et que l'affaire était donc en état d'être jugée par le TA. Elle en a déduit que le TA devait donc bien statuer sur la requête, comme il l'a fait, en application de l'article R. 634-1 du CJA – qui n'oblige à suspendre la procédure en cas, notamment, de décès de l'une des parties, que si l'affaire n'est

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

pas en état d'être jugée. Puis, s'appuyant sur ce que la reprise d'instance ne pouvait donc avoir aucune incidence sur la poursuite de la procédure (l'affaire étant « *en l'état d'être jugée* », qu'il y ait ou non reprise d'instance), la cour en a déduit que l'absence de communication du mémoire de reprise d'instance n'avait pas préjudicié aux droits de la société.

Le premier temps de ce raisonnement, sur le fait que le TA devait de toute façon statuer, nous paraît exempt d'erreur de droit. Le décès d'un requérant en cours d'instance ne provoque en effet « *l'extinction de l'action et le prononcé d'un non lieu pur et simple que si l'action a un caractère personnel* » (cf. conclusions de la présidente Fombeur sur votre décision du 13 janvier 2003, *Mme E...*, n° 244844, aux T.). Or vous n'avez reconnu le caractère personnel de l'action que dans des cas très limités :
- en matière électorale, depuis fort longtemps (11 juillet 1968, *El. d'Ajaccio*, p. 655 ; 26 février 1875, *Delhomet*, p. 116 ; 18 juillet 1884, *El. de Luzech*, p. 625 ; c'est donc une solution plus que centenaire, comme le rappelait votre commissaire du gouvernement D. Piveteau dans ses conclusions sur la décision du 24 mai 1996, *El. minicipales d'Anse*, 172002, au rec. p. 250, appliquant la même solution à un scrutin de liste, les colistiers ne pouvant pas non plus reprendre l'instance) ;
- en matière de contravention de grande voirie (24 février 1989, *Secrétaire d'Etat à la mer c/ A...*, T. p. 857) ;
- et les quelques rares tentatives en dehors de ces deux cas de figure, qui portent essentiellement sur des décisions de sanction, n'ont en revanche pas connu de postérité. Voyez, en matière d'admission d'office à la retraite : 27 mai 1889, *Picard-Destelan*, p. 436, solution sur laquelle revient un arrêt, relatif lui aussi à une sanction, du 17 décembre 1954, *Sieur B...*, T. p. 869, AJDA 1955. 111, avec note Copper-Royer ; plus récemment, si vous vous n'avez pas admis la reprise d'instance en cas de sanctions prononcées à l'encontre d'un fonctionnaire par la CDBF (21 juillet 1989, *A...*, n° 99258, T. p. 857), vous êtes rapidement revenus sur la portée de cette décision, que ce soit dans le champ des amendes infligées par la CDBF (cf. 29 mars 1999, *L...*, n° 159445, T. p. 958) ou dans celui, plus général, des sanctions disciplinaires dans la fonction publique (voyez 28 février 2007, *C...*, n° 284858, aux T., aux éclairantes conclusions de L. Vallée).

Nous voyons mal, compte tenu de l'orientation de votre jurisprudence, comment vous pourriez admettre le caractère personnel de l'action en matière de licenciement de salariés protégés. Par conséquent, il fallait bien appliquer au litige l'article R. 634-1 du code de justice administrative.

Si ces dispositions avaient été prévues à l'origine pour le recours de plein contentieux, vous les appliquez depuis longtemps au contentieux de l'excès de pouvoir (22 novembre 1967, *Balin*, n° 70581, aux T. ; 17 déc. 1954, Serre, préc.). Ce texte est en effet vénérable : il est issu de l'article 62 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat, qui lui-même reprend l'article 22 du décret du 22 juillet 1806, inspiré de l'article 342 de l'ancien code de procédure civile prévoyant que *« Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé ni par le changement d'état des parties ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués* » (cf. Louis Boré, *La suspension de l'instance devant le juge administratif*, Droit administratif n° 11, novembre 2005, étude 17). C'est donc cette solution, ancienne, qui continue de s'appliquer devant vous – alors que, devant le juge judiciaire, les textes ont été refondus en 1975, le nouveau code de procédure civile prévoyant dorénavant

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

que l'instance est « *interrompue par le décès d'une partie* » (dans les cas où l'action est transmissible).

Ainsi, devant le juge administratif, lorsque l'action n'a pas un caractère personnel et que l'affaire est en état d'être jugée, l'instance va jusqu'à son terme, même si aucun héritier ne déclare spontanément reprendre l'instance (cf. 16 mai 1947, *Marchal*, T. p. 673 ; 21 novembre 1952, *Boulmer*, p. 526 ; 25 novembre 1955, *Mauranne*, T. p. 777). Et, si l'affaire est en l'état mais que les héritiers forment des conclusions à fin de non-lieu, vous les regardez comme équivalentes à un désistement pur et simple (30 mars 1966, *Casati*, n° 57218, au rec.). Inversement, si l'affaire n'est pas en état, vous prononcez alors un non-lieu à statuer (23 octobre 1935, *Moreau*, Rec. p. 975 ; 19 juin 1968, *Berthollet*, T. p. 1060). Enfin, vous jugez qu'une affaire est « *en état d'être jugée* » lorsque les échanges entre les parties ont été au moins jusqu'à la production d'un mémoire en défense (voyez 25 novembre 1955, *Mauranne*, préc. ; 19 juin 1968, *Berthollet*, T. p. 1060).

La cour ne s'est donc pas trompée en jugeant que, dès lors que l'affaire était « *en l'état* », le décès de M. A...n'avait pas suspendu la procédure et que la reprise d'instance n'avait pas d'incidence sur le déroulement de la procédure.

Mais le second temps de son raisonnement nous paraît plus critiquable. La cour a souhaité appliquer votre jurisprudence du 7 juillet 2004, *Communauté d'agglomération du Val de Garonne*, n° 256398, aux T., qui juge qu'il résulte des dispositions de l'article R. 611-1 du CJA que si le défaut de communication du premier mémoire en défense est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité, tel n'est pas le cas s'il ressort des pièces du dossier que cela n'a pas préjudicié aux droits des parties. Or elle a considéré que l'absence de communication au défendeur du mémoire de reprise d'instance ne lui avait pas préjudicié puisque la reprise d'instance n'était pas susceptible d'affecter le cours de la procédure : autrement dit, le défendeur n'avait pas besoin de la contester pour éviter un non-lieu, dès lors que l'affaire était en état d'être jugé. C'est uniquement lorsqu'une affaire n'est pas en état d'être jugée qu'une reprise d'instance est nécessaire pour éviter le non-lieu, et que la contestation de sa recevabilité revêt alors un enjeu pour lui (cf. Section, 12 novembre 1949, *Vechini*, rec. p. 480).

Mais la communication du mémoire d'instance avait aussi, nous semble-t-il, un autre enjeu : celui, pour le défendeur, de pouvoir tirer toutes les conséquences de la reprise d'instance, et notamment de contester la qualité des personnes reprenant l'instance pour tenter d'éviter, le cas échéant, que leurs nouvelles écritures – assorties éventuellement de nouveaux moyens voire de nouvelles conclusions – voire l'intervention de leur avocat à l'audience, via des observations orales ou une note en délibéré, puissent être prises en compte par le juge. Autrement dit, en cas de contestation de la reprise d'instance, ce n'est pas du tout le non-lieu qui est en jeu, mais la cristallisation du débat à la date du décès du requérant.

Faut-il alors considérer que l'absence de communication d'un mémoire de reprise d'instance entache systématiquement d'irrégularité la procédure ? Il nous semble que non et qu'il peut y avoir une place pour l'application, comme la cour a tenté de le faire, de votre jurisprudence *Val de Garonne*. Mais à condition de bien prendre en compte tous les paramètres en jeu. En l'espèce, nous avons été tentée, dans un premier temps, de considérer qu'une annulation serait sévère, car le mémoire de reprise d'instance, au dossier, ne va guère au-delà de la reprise d'instance elle-même, et n'est pas assorti d'autres conclusions. Sauf qu'il ressort des visas du

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

jugement que le conseil des intéressés a prononcé des observations à l'audience, et du dispositif de ce même jugement que le TA leur a attribué des frais irrépétibles, alors que la société défenderesse n'avait pas été régulièrement informée qu'ils étaient dans la cause.

Dans ces conditions, nous pensons que la cour, en se fondant, pour appliquer votre jurisprudence *Val de Garonne*, sur la seule circonstance que l'affaire était en état d'être jugée, a effectivement commis une erreur de droit, et nous vous proposons de casser son arrêt sur ce motif.

2. Ajoutons, si vous ne nous suiviez pas sur ce point, que l'autre moyen invoqué, tiré de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé que l'autorisation de licencier M. A...était intervenue au terme d'une procédure irrégulière et avait privé l'intéressé d'une garantie, ne nous paraît pas fondé.

Est critiqué le considérant 5 de l'arrêt indiquant qu'il ressortait des pièces du dossier que l'inspectrice du travail s'était fondée sur les PV que l'entreprise avait fait établir par huissier et mentionnés dans la demande d'autorisation de licenciement, mais que, d'après les écritures en défense de la DIRECCTE de Lorraine devant le TA, cette inspectrice, lorsqu'elle a reçu M. A... (les 27 mars et 26 avril 2012), « lui aurait lu les courriers de l'employeur sans préciser lesquels et lui aurait soumis les pièces invoquées au fur et à mesure par chaque courrier, sans davantage préciser la nature des pièces et notamment sans indiquer qu'il s'agissait des PV de constats d'huissier (…) », que, par conséquent il n'était pas établi que l'existence de ces PV ait été mentionnée au salarié pendant l'enquête préalable ni que ce dernier a été informé de son droit d'accéder à ces pièces. La CAA en a déduit que la procédure a été irrégulière.

Ce faisant elle a appliqué strictement votre jurisprudence issue des arrêts de Section du 24 novembre 2006, R..., 284208, au rec. ; 9 juillet 2007, S..., n° 288295, aux T. ou encore du 15 décembre 2010, Société Fournier, 325838, aux T ., selon lesquelles le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'IT, préalablement à l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, impose que ce dernier puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, et soit, à peine d'irrégularité de la procédure, informé non seulement de l'existence des pièces de la procédure, mais aussi de son droit à en demander la communication.

Or les pièces sur lesquelles s'est appuyée la CAA – mémoire en défense de la DIRECCTE notamment – sont, de fait, peu précises, alors même qu'il ressort du dossier que la demande de l'employeur auprès de l'IT comportait 26 pj – il est donc difficile de considérer que la seule lecture du courrier de demande d'autorisation de licenciement de l'employeur, par l'IT au salarié protégé, aurait permis à l'intéressé de prendre connaissance des pièces en question. Le moyen de dénaturation n'est donc pas fondé.

Quant à l'erreur de droit qui aurait consisté, pour la cour, à exiger de l'administration du travail un effort excessif en matière de preuve de ce que le salarié avait effectivement été mis à même de prendre connaissance des documents litigieux, elle n'est pas non pus fondée : la cour a simplement examiné les différents éléments dont elle disposait et a considéré que, par rapport à l'argumentation du salarié indiquant qu'il n'avait pas eu connaissance des éléments litigieux, ceux produits par l'administration du travail ne suffisaient pas à démentir cette affirmation. Si vous ne nous suiviez pas sur le premier moyen, ce deuxième moyen ne permettrait donc pas la cassation de l'arrêt.

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

PCMNC à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de l'affaire devant la CAA de Nancy ; vous pourrez, dans les circonstances de l'espèce, rejeter les conclusions de la requérante au titre de l'article L. 761-1 CJA, et rejeter ces mêmes conclusions présentées en défense.

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.